

1503728-04.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041149/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 22987890 - 63º D.P. VILA JACUI, 2041149 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE CAWAN NERIS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503728-04.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503728-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041149/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 22987890 - 63º D.P. VILA JACUI, 2041149 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIQUE CAWAN NERIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

CAIQUE CAWAN NERIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, como narra a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua

Cumaru nº 14, Vila Nitro Operaria, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 22 porções de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida por "maconha", com massa líquida total de 37,8g (trinta e sete gramas e oito decigramas), e 23 porções de cocaína, com massa líquida total de 9,8g (nove gramas e oito decigramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O denunciado foi notificado. Houve oferecimento de defesa preliminar. A denúncia foi recebida, seguiu-se citação. Em instrução, foram ouvidas testemunhas comuns e outras três de Defesa. Interrogado, o acusado negou a imputação. Nos debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, enquanto a Defesa manifestou-se, em preliminar, pela instauração de incidente toxicológico e, no mérito, pela absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo o apurado, na data e local indicados na denúncia, policiais militares faziam patrulhamento pela região quando visualizaram o acusado e outro indivíduo não identificado. Estes, ao avistarem a viatura, evadiram-se do local, sendo certo que CAIQUE, ao se evadir, dispensou uma sacola que trazia nas mãos.

Ao ser abordado pelos policiais e em revista pessoal, foi constatado que o réu trazia em sua posse, escondido em sua cueca, 23 (vinte e três) eppendorfs contendo cocaína, e, na sacola por ele dispensada, 22 (vinte e dois) invólucros plásticos contendo maconha.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

Igualmente a autoria é certa.

O policial militar Ricardo de Faria Claro disse que, em diligências pelo local dos fatos, avistaram dois indivíduos na esquina, por volta das 10:30 horas. Estes, ao notarem a presença dos policiais, saíram do local, com sinais de nervosismo, razão pela qual decidiram abordar o agente que estava com uma sacola plástica transparente em mãos. Ressaltou que tal agente, ora réu, jogou a sacola junto ao poste. Assim, a equipe desembarcou, pegou a sacola, e efetuou a abordagem. Em revista pessoal pelo cabo Baeta, dentro da cueca do acusado, foi localizado parte das drogas (22 porções de cocaína). Em averiguação na sacola, antes dispensadas, foram localizadas as demais porções da droga. Houve resistência do acusado ao ser detido. Não se recorda da apreensão de dinheiro, uma vez que, segundo o próprio acusado, ele ainda não tinha feito qualquer venda naquele dia. O ponto onde abordado o acusado é palco de frequentes prisões por tráfico de entorpecentes. Depois da prisão do acusado ao local compareceu uma parente do ora réu, acredita seja sua irmã. Em nenhum momento o acusado se disse usuário; ao contrário, prontamente confessou o fato.

No mesmo sentido, em suma, o quanto narrado pelo policial militar Marcos Roberto Alves Baeta.

A testemunha de defesa Adriana de Castro Nunes disse que conhece o acusado há cerca de 06 anos, assim como sua família. Sobre a prisão do acusado não a presenciou. Sabe dizer que o réu, contudo, é apenas usuário, não traficante. Uma outra vez ele já tinha sido preso, também como traficante, quando comprava droga. É de

conhecimento geral que Caíque é usuário de entorpecentes, finalizou a depoente.

A testemunha de defesa Caroline Cristina da Silva disse que Caíque é seu conhecido desde infância, eis que “cresceram juntos” (sic). O acusado “é usuário” (sic). Ele, Caíque, é usuário de “farinha” (sic).

Já a testemunha de defesa Evelin Roseli Gabaldi disse que conhece toda a família do acusado. O réu é usuário de drogas há bastante tempo. Mora “perto da biqueira” da rua Cumaru (sic). A “rua toda comentou sobre a prisão do acusado”, que se deu “quando ele foi comprar” (sic). Não presenciou o momento da prisão. O comentário “foi de que ele foi preso vendendo droga e que estava trabalhando na biqueira” (sic), embora “tenha certeza de que ele não estava vendendo” (sic).

Interrogado, o réu disse que no domingo, dia do fato, foi comprar drogas para seu consumo (maconha e cocaína). Com a aproximação da viatura policial, o traficante correu e acabou detido. Disse aos policiais que tinha comprado aquela droga do traficante que saiu correndo. Resistiu à prisão por conta de ser mero usuário, não aceitando aquela acusação. Tinha três pinos de cocaína e outra porção de maconha. Começou a pedir por socorro na rua, porque não queria ser detido e os policiais o agrediam. Já havia sido detido nas proximidades daquele local, também em ocasião em que estava apenas comprando a droga.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação do acusado.

O réu foi flagrado em poder de expressiva quantidade e variedade de drogas, a evidenciar a um só tempo a autoria e a destinação das drogas ao comércio ilícito.

A forma de separação dos entorpecentes e a tentativa de subtrair-se à ação policial, igualmente reforçam a destinação da mercadoria.

Por outro lado, a alegação comum da Defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção juris tantum de agir escorreitamente, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade. Até mesmo porque o policial “deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...”.

Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a Suprema Corte, não torna a testemunha impedida ou suspeita.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende.

Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando não contraditados em Juízo, o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

Alfim e ao cabo, é certo que, mesmo seja o vendedor também um usuário de entorpecentes, que assim procede na traficância para sustentar sua drogadição, não

há se cogitar em absolvição ou desclassificação da conduta.

A lei já discrimina a figura daquele que, sendo usuário, fornece drogas, com caráter de eventualidade e sem visar lucro, a pessoa de seu círculo vicioso para juntos consumirem os entorpecentes – artigo 33, parágrafo terceiro, da Lei n. 11.343/2006.

Os papéis de usuário e traficante podem imbricar-se, sem que, com isso, se afaste a figura do tráfico.

Ademais, vale destacar que o acusado está preso há aproximadamente quatro meses, o que evidencia que a medida de exame toxicológico é contraprodutiva, dado que não refletiria propriamente os hábitos e adições contemporâneas aos fatos, reforçando a conclusão de desnecessidade da prova visada.

Portanto, a denúncia procede.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, observo que se cuida de acusado portador de maus antecedentes.

Efetivamente os maus antecedentes se comprovam e não podem ser desprezados para a individualização da pena.

Com efeito, não se pode equipará-los à reincidência, vez que são elementos distintos previstos pelo legislador para a atribuição do justo concreto em termos de apenamento.

“Por antecedentes se devem entender os fatos anteriores praticados pelo réu, que podem ser bons ou maus. São maus antecedentes aqueles fatos que merecem a reprovação da autoridade pública e que representam expressão de sua incompatibilidade com os imperativos ético-jurídicos. A finalidade desse modulador, como os demais constantes do art. 59, é simplesmente demonstrar a maior ou menor afinidade do réu com a prática criminosa”.

A reincidência é fenômeno muito mais restrito, para sua caracterização, em relação aos maus antecedentes, segundo o artigo 59 do Código Penal, cada qual deles merecendo seu próprio tratamento normativo. Não é razoável, portanto, que se aplique o chamado “período depurador” da reincidência aos maus antecedentes, porque isso implica, necessariamente, em não individualizar a pena, segundo o mandamento constitucional.

“O conceito de antecedentes é muito mais amplo do que o de reincidência. Dentro dele são considerados tanto os fatos negativos quanto os positivos da vida do agente. Uns e outros constituem uma volta ao passado e devem ser considerados pelo juiz para a determinação da pena justa e adequada”.

Assim, com devida vênica de entendimentos diversos, a interpretação oposta, no sentido de se apagarem os maus antecedentes pelo decurso do tempo, mostra-se desarrazoada e inconstitucional, vez que deixa de considerar características pessoais do agente para a formação de reprimenda penal.

Sim, pois que assim estaríamos dando por letra morta o comando legal, vez que antecedentes e reincidência seriam exatamente a mesma coisa para efeitos penais.

Ademais, quando o legislador fala em 'antecedentes', necessariamente tem em vista fatos pretéritos da vida, da conduta social do agente, que constituem uma história de vida, indispensável para se aquilatar a sua culpabilidade. O considerar de tais

condições, históricas, não conduz a nenhuma perpetuidade da pena, na medida em que não se tem qualquer punição exclusivamente em vista de outra condenação, passada. A pena deve ser exasperada pela condição de maior desvalor de conduta do agente na comunidade, que necessariamente não pode ser restrita a um lustro.

Não nos parece seja esta a necessária individualização da pena prevista por nossa Constituição Federal.

Em suma, o chamado “período depurador” da reincidência não se presta a afastar os maus antecedentes. É entendimento consolidado junto ao C. STJ, assim como matéria pacificada em recente decisão do C. STF, ao apreciar a questão em sede de repercussão geral, decidindo que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”

Na doutrina, no mesmo sentido ora defendido, encontramos o posicionamento de NUCCI.

Por fim, confirmando o presente entendimento, o RESp. n. 1.712.268/SP, do C. Superior Tribunal de Justiça, originário desta Vara, validando o entendimento ora esposado.

Assim, as penas iniciais partem de 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mínimos.

Cabível, na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que o delito fora praticado em meio à pandemia ocasionada pelo COVID.

E, no ponto, descabe falar que a conduta em nada fora afetada, ou que ela nada afetou, o mundo fenomênico. Absolutamente. Primeiro porque, como cediço, situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, no caso, da pandemia. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Depois, porque todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, representa maior gravame, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independe de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, “essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime”. Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha.

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva.

Desnecessário acrescentar, por outro lado, que conforme já pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal, prescindível a enumeração das agravantes na denúncia para que sejam reconhecidas pelo julgador. “Deveras, pelo princípio da congruência (...) o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Dessarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a expressa qualificação na denúncia de eventuais causas de aumento ou de diminuição de pena”.

Ademais, cuida-se de acusado reincidente específico. Como cediço, maior o desvalor da conduta daquele que reitera na prática de determinado crime, pois evidencia que faz da delinquência conduta corriqueira, fato que merece reciprocidade em termos

penais, como entende, inclusive, o C. Supremo Tribunal Federal.

Elevo, pois, a pena para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, mínimos.

Frisa-se a circunstância para que não se levante o duplo agravamento por mesmo fato (reincidência e maus antecedentes como mesmo suporte). A situação aqui é diversa, como reiteradamente proclama o C. STF.

Incabível o benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de Regência, posto reincidente o acusado. Isso não induz, ademais, a qualquer alegação de dupla exasperação da pena por idêntico motivo, como afirma também o C. STJ.

Em vista da reincidência específica e dos maus antecedentes já apontados, deverá iniciar o desconto da pena em regime inicial fechado. De todo modo, a pena imposta não comportaria regime diverso.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu CAIQUE CAWAN NERIS, qualificado nos autos, à pena de para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 874 (oitocentos e setenta e quatro) dias-multa, mínimos, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Inviável o recurso em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. Ademais, como visto, temos acusado em intensa reiteração delitiva, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

RECOMENDE-SE o réu nas prisão em que se encontra.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

Richard Francisco Chequini
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA